

1500898-05.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... à pena de dez anos por outro tráfico.

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Diversamente do alegado pela defesa, a prova policial é coesa.

O policial Anderson pilotava a viatura e ratificou as declarações constantes no boletim de ocorrência.

Já o policial Guilherme, que fez a abordagem, disse que estavam acerca de 30 a 50 metros do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500898-05.2020.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500898-05.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225415/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 13530793 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 11250/20/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2225415 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA DA FONSECA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado André Luiz de Oliveira da Fonseca, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 11 de setembro de 2020, às 20h30min, na Rua José Pires de Camargo, esquina com a Rua Alziro Zarur, bairro Parque Olímpico, na cidade de Bauru/SP, o acusado foi surpreendido com 69,4 gramas de maconha, para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 18), laudo de constatação preliminar (fls. 14/17) e laudo definitivo (fls. 128/131).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise formal (fls. 46/49), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva, a qual foi substituída pela modalidade domiciliar.

Pela decisão de fls. 93/95 foi recebida a denúncia e determinada a notificação e citação do acusados

O réu foi formalmente citado (fls. 106), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 120).

Na decisão de fls. 133/134, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Pela decisão de fls. 180/184, foi revogada a prisão domiciliar e decretada a prisão preventiva do acusado.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 204/206 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 211/216 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a exasperação da pena-base em função do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a valoração da agravante do "estado pandêmico" e da atenuante da menoridade relativa; o afastamento do "tráfico-privilegiado" e a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 220/229 pleiteou, em síntese, a absolvição por ausência de provas, ou a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante do "estado pandêmico" pela ausência de nexo causal com o delito em exame; com o emprego da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a substituição da privativa por restritivas de direitos, e a possibilidade do manejo de eventual recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 18), laudo de constatação preliminar (fls. 14/17) e laudo definitivo (fls. 128/131).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial Guilherme Reuel da Silva Castro, na fase judicial (mídia SAJ) disse, em resumo, que estava com seu parceiro, em local de tráfico (Esquina do "Bosque Geisel"), e, quando avistaram o acusado, ele jogou algo. Afirmou que ele correu e virou a esquina. Informou que voltou ao local e localizou dois pacotes de maconha. Esclareceu que, na abordagem, ele disse que iria ao centro para vender os entorpecentes que havia adquirido no Bairro Ferradura Mirim. Mencionou que a mãe apareceu, posteriormente. Citou que estavam distantes, aproximadamente, de 30 a 50 metros (ainda no interior da viatura) e, com o acusado, foi apreendida a quantia de cerca de R\$ 68,00, em notas miúdas. Asseverou que não fizeram campanas.

O policial Anderson Lopes de Araújo, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), ratificou o que constava no boletim de ocorrência. Disse que estava na direção da viatura e o colega era o soldado Castro.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado André sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a traficância. Disse que foi abordado pela polícia na via pública e que a droga encontrada pelos policiais não lhe pertencia. Afirmou que já foi condenado à pena de dez anos por outro tráfico.

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Diversamente do alegado pela defesa, a prova policial é coesa.

O policial Anderson pilotava a viatura e ratificou as declarações constantes no boletim de ocorrência.

Já o policial Guilherme, que fez a abordagem, disse que estavam acerca de 30 a 50 metros do acusado (ainda na viatura) e viram ele dispensaram a droga.

Depois da abordagem, ele confessou a traficância, tendo restado delineado que a droga era maconha.

De se citar, ainda, que o acusado já foi condenado por delito análogo e foi abordado com cerca de R\$ 68,00, em notas miúdas, no bolso da bermuda, salientando-se que é desempregado e nunca trabalhou (fls. 21).

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Sob outro aspecto, deve o acusado André permanecer custodiado.

O acusado quando preso em flagrante no presente feito, tinha em seu favor o benefício da liberdade provisória nos autos nº 1500138-56.2020.8.26.0594.

Depois, após os fatos aqui delineados, foi preso em flagrante em 16/02/2021 por ter cometido os crimes de tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menores (feito nº 1500185-93.2021.8.26.0594).

Além disso, possui em seu desfavor passado deletério perante o D. Juízo Infracional (fls. 38).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade

(formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Réu André Luiz de Oliveira da Fonseca

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

A natureza - maconha - e a quantidade, cerca de 69,40g dividida em duas porções, não permitem a exasperação, sempre preponderante, da pena-base.

Por isso, a pena deve permanecer no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, deve ser valorada a menoridade relativa, sem repercussão, contudo, na reprimenda imposta, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, tendo como parâmetro anterior, há delito pretérito, posterior e atos infracionais praticados na seara infanto-juvenil, relacionados, sempre, com o tráfico de drogas.

Por isso, a única conclusão razoável é que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO.

SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA

HEDIONDEZ DO DELITO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Se no interregno entre a prática de um delito de tráfico e a correspondente sentença condenatória o acusado vem a cometer outro delito da mesma ou de natureza diversa, indicando a "dedicação às atividades criminosas", poderá o julgador afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, instituto reservado para aqueles em que o tráfico se afigura como um evento isolado em suas vidas. 2. In casu, no momento da prolação da sentença condenatória, o magistrado a quo ressaltou que o réu já cumpria pena por tráfico e exploração de jogos de azar, delitos os quais, embora se refiram a fatos posteriores aos ora versados, servem para o fim de negar o reconhecimento do privilégio.

(...)

(STJ, 6ª Turma, HC nº 408.674 - SP, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28/11/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na variedade dos entorpecentes apreendidos - 81,5g maconha e 30,7g cocaína -, na própria confissão do agente e nos registros de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio e de furto que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 447045 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07/08/2018).

Por isso, a pena-base é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

O réu André é vezeiro na traficância, e, por isso, sua conduta é de gravidade concreta.

Por isso, o regime mais gravoso é o único capaz de reprimir (com a esperada ressocialização) e, de maneira mais importante, prevenir novas ocorrências.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006.

PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NÃO DESPREZÍVEL. ATIVIDADE CRIMINOSA.

DEDICAÇÃO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Embargos de declaração, apresentados dentro do quinquídio legal, devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.

2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentos idôneos a

justificar tanto a imposição do regime mais severo quanto o indeferimento da substituição das penas.

3. Para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa.

4. A dedicação à prática da mercancia ilícita, consistente em seu modo reiterado e habitual, pela quantidade expressiva de droga apreendida - 977,3 gramas de maconha -, aliada, ainda, às circunstâncias do caso concreto, constituem-se em fatores legais à negativa da aplicação do redutor prescrito na Lei de Drogas.

5. Não há ilegalidade na manutenção do regime fechado, pois, embora o quantum de pena aplicado permita, em tese, a fixação do regime intermediário, a quantidade de entorpecente apreendida, aliada às circunstâncias do caso concreto, de igual modo, justificam a imposição do regime prisional mais gravoso.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, 6ª Turma, EDcl no HC 567883 / SP, relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 09/06/2020)

A quantidade de pena imposta e o regime de aplicação impedem a substituição da corporal por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, CONDENO o réu André Luiz de Oliveira da Fonseca, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado André o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto ao aparelho celular e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA